

1508533-20.2021.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... não há dúvida de que o acusado estava a cometer o tráfico.

É necessária a análise conjunta dos requisitos previstos no art. 28, §2º da Lei 11.343/06 para a distinção entre o usuário e o traficante.

No caso, o réu trazia, em seu estomago, porções de maconha em quantidade mais do que suficiente para caracterização do tráfico.

É certo que tal quantidade poderia também ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508533-20.2021.8.26.0071 - lauda

\SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508533-20.2021.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2270521/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 14978968 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 29684/19/404 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 30045/19/404 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2270521 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS DE MORAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

MARCOS VINICIUS DE MORAES foi dado como incurso nas penas do art. 33, caput, combinado com art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 19 de dezembro de 2019, por volta das 19h00, nas dependências e imediações do Centro de Progressão Penitenciária II de Bauru, nesta cidade, transportava e trazia consigo, para fins de tráfico, 127,39 gramas de maconha, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 164), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 168/169.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 24 de novembro de 2021 (fls. 175/177).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 209 - audiovisual; e fls. 232/255 - transcrição ).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 226/229).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 258/265, alegando que: 1)- o réu não era conhecido como traficante, não havia delação anônima e não haveria motivo para que ele fosse vender droga na penitenciária há apenas quatro dias da saída temporária; 2)- a conduta deve ser desclassificada para a prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois o réu declarou consumir cerca de 20 a 22 gramas por dia, e iria permanecer na penitenciária por quatro dias até a saída temporária; 3)- a quantidade de droga apreendida é compatível com o discurso do acusado. Pediu a absolvição e, alternativamente, a desclassificação da imputação inicial para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 e a fixação do regime inicial semiaberto.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 10 e pelo laudo pericial de fls. 106/109 (quatorze porções de maconha com peso de 98 gramas). A autoria e o intuito de traficância derivam da prova oral e das circunstâncias do caso e devem ser atribuídos ao acusado.

Em juízo, a testemunha Luiz Fernando da Cunha, agente de segurança penitenciária, afirmou que não se recordar dos fatos, pois já faz muito tempo e todo dia acontecia uma novidade no estabelecimento prisional (fls. 232/236).

A testemunha Andreia dos Rios, agente de segurança penitenciária, disse que trabalha no setor de disciplina e registra a maior parte dos boletins de ocorrência na delegacia. O suspeito não foi levado à delegacia. Levou apenas o material apreendido no estabelecimento prisional. Não se lembra do aspecto do objeto (fls. 237/239).

A testemunha Hélder Fabio Miguel, agente de segurança penitenciária, informou que o réu estava retornando do trabalho externo e foi submetido ao scanner, quando então se verificou uma imagem estranha. Ele tentou fugir, passando pelo primeiro alambrado. Quando o acusado chegou no segundo alambrado, foi detido. Ele expeliu, através de vômito, seis invólucros de maconha. Viu a droga expelida. Não se recorda se o réu deu alguma explicação. Não se lembra também em qual local ele trabalhava. O acusado tentou se evadir, haja vista que o recinto do scanner fica com a porta aberta. Na fuga, ele se lesionou no pé, em razão de ter colidido com a concertina do alambrado (fls. 241/245).

Interrogado em juízo, o réu declarou que já sofreu muito na vida em razão do vício em drogas. Foi preso várias vezes por ser viciado. Foi preso por tráfico sem ser traficante. Não podia indicar o traficante pois, do contrário, seria morto na comunidade onde mora. Caiu na besteira por causa do vício nos dias que antecederam a "saidinha" de dezembro. Comprou o entorpecente perto da empresa na qual trabalhava, qual seja, "MR". A três quarteirões do estabelecimento, havia um mercado e um bar, onde um rapaz vende drogas. Comprou o entorpecente com a intenção de levar para dentro da unidade. O material destinar-se-ia ao seu uso próprio. É muito caro comprar drogas dentro da unidade prisional. O rapaz vende a droga e recebe o pagamento quando os detentos saem na "saidinha". Iria fazer o pagamento posteriormente. Enrolou as porções em um plástico e engoliu. Iria vomitar as drogas para poder fumar. Está decepcionado consigo mesmo. Pede perdão a todos. A passagem pelo scanner é feita por amostragem. De cada dez ou quinze, somente três ou quatro são submetidos ao aparelho. Achou que não passaria pelo scanner. Pagou cinquenta reais pelo entorpecente. Iria pagar na "saidinha", pois trabalhava como soldador e somente receberia o dinheiro quando saísse. O dinheiro do pecúlio normalmente é retirado pela família. Contudo, quando não se retira o dinheiro, a unidade paga em mãos ao detento a cada três ou quatro meses, quando da saída temporária. Iria gozar a saída dali três dias, quando então receberia o dinheiro e pagaria o rapaz. Recebia seiscentos e quarenta e seis reais por mês. Trabalhava há vinte dias. Antes, trabalhava em outra empresa. Tem especialidade como soldador e bom

currículo. Já trabalhou na "Caloi" e "Eletrolux". Os fatos ocorreram no dia dezenove e a "saidinha" seria no dia 23. Iria consumir a droga nos quatro dias de intervalo, pois estava muito ansioso. Consome cerca de sete ou oito gramas de maconha por dia. Cada cigarro tem três gramas. Fuma um cigarro de manhã, um no horário de almoço, mais um depois do almoço e um quarto, antes de dormir. Consome cerca de 20 a 22 gramas por dia. Trabalhava das sete horas da manhã até as quatro ou quatro e meia da tarde (fls. 247/255).

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.

O fato e sua autoria estão bem demonstrados.

Em primeiro lugar, o réu confessou que trazia porções de maconha em seu estômago visando adentrar com elas no presídio, embora ressaltando que pretendia consumi-las.

Da mesma forma, o agente de segurança penitenciária Hélder afirmou ter visualizado imagem estranha quando o acusado se submeteu ao scanner corporal e notou que ele expeliu a droga.

As afirmações do agente se afiguram firmes, coerentes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de agentes públicos encarregados da manutenção da ordem.

À propósito:

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

E, especificamente em relação a depoimentos de agentes de segurança penitenciários: "(...) o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e harmônica a utilização, pelo paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão." (HC 254.312/Sp, rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/08/2013, DJE 13/08/2013). (em TJSP, Apelação n. 0029345-41.2013.8.26.0071, rel. Silmar Fernandes, j. 13/11/2015).

Destarte, o fato descrito na denúncia, objetivamente considerado, e respectiva autoria restaram provados.

Por outro lado, não há dúvida de que o acusado estava a cometer o tráfico.

É necessária a análise conjunta dos requisitos previstos no art. 28, §2º da Lei 11.343/06 para a distinção entre o usuário e o traficante.

No caso, o réu trazia, em seu estômago, porções de maconha em quantidade mais do que suficiente para caracterização do tráfico.

É certo que tal quantidade poderia também indicar porte para mero consumo.

Ocorre que as demais circunstâncias do caso permitem aferir a intenção de entrega da maconha a terceiro (s).

Veja-se que a justificativa apresentada pelo acusado em seu interrogatório, no sentido de que precisava entrar com o entorpecente na penitenciária para consumo durante quatro dias, não é coerente nem convincente.

Ele próprio afirmou que comprou a droga quando realizava trabalho externo.

Ora, se ele realizava trabalho externo e se fosse mero consumidor de entorpecente, muito menos arriscado e cômodo seria fazer o uso diário da droga nos momentos em que estivesse fora do presídio, a serviço.

Se, em tais momentos, fosse flagrado apenas com a quantidade de droga indispensável ao consumo, jamais seria suspeito de estar praticando tráfico.

A narrativa de que o réu permaneceria no interior da unidade prisional por quatro dias, até a data de gozo da saída temporária, no próximo dia 23 de dezembro de 2019, uma segunda-feira, não é verossímil.

O fato se deu no dia 19, uma quinta-feira.

Sendo sexta-feira dia útil, não é razoável supor que não haveria trabalho externo no dia seguinte ao do ocorrido.

Se de fato não haveria trabalho externo naquela sexta-feira, caberia à defesa a respectiva comprovação, por se tratar de situação inusual.

Sendo assim, não haveria razão para se correr o risco de trazer para dentro da unidade prisional tamanha quantidade de entorpecente, a ser utilizada durante quatro dias.

Paralelamente, conduta consistente em trazer razoável quantidade de maconha no estômago, observado seu elevado risco para a saúde e mesmo o de incriminação por tráfico (inclusive em face da probabilidade de ser submetido ao scanner), somente se justifica se se pensar que o agente quer atingir vantagens bem maiores do que a advinda da satisfação derivada do consumo.

Aliás, se o réu auferia R\$ 646,00 por mês, e se poderia receber o rendimento de seu trabalho decorrente do período de três meses quando do gozo de saída temporária, o mais lógico e racional seria que utilizasse o numerário em questão para comprar droga mesmo dentro do estabelecimento prisional, ainda que pagando mais caro.

Insista-se que o risco para a saúde e de incriminação por tráfico era sensivelmente maior ao ter que transportar droga no estômago e se submeter ao scanner corporal. Muito mais vantajoso e bem menos arriscado, com efeito, seria desembolsar um tanto mais de dinheiro e comprar o entorpecente na própria penitenciária.

Valeria a pena correr tamanho risco de sofrer grave dano à saúde e de sofrer condenação criminal a pena deveras longa, se se poderia tudo isso evitar, apenas gastando um pouco mais de dinheiro, que o réu confessadamente tinha?

Tampouco vinga a tese de que não haveria razão para o acusado traficar faltando quatro dias para a saída temporária.

A defesa não justificou a razão de seu argumento, sabido que o tráfico é lucrativo mesmo em tais circunstâncias.

Destarte, não há como absolver, e nem mesmo como desclassificar a conduta para a prevista no artigo 28 da Lei n. 11343/2006.

Ao revés, o réu deve ser condenado na forma proposta na denúncia.

Passa-se à aplicação da pena.

O réu possui maus antecedentes (fls. 149/150 – art. 155, caput, c.c. art. 14, inciso II, do Código Penal; e fls. 150 – art. 155, caput, c.c. art. 14, inciso II, do Código Penal).

Diante disso, fixa-se a pena base em um oitavo acima do mínimo legal, ou seja, cinco anos, sete meses e quinze dias de reclusão, mais quinhentos e sessenta e dois dias-multa.

O réu é reincidente (fls. 149 – art. 33, caput, da Lei 11.343/06; e fls. 150/151 – art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal).

Considerando a agravante da reincidência, ensejada por duas condenações anteriores, a pena deve ser majorada na proporção de um quinto, resultando em seis anos e nove meses de reclusão, mais seiscentos e setenta e quatro dias-multa.

No tocante à causa de aumento de pena, restou comprovada, pois o crime foi cometido quando o réu estava nas dependências de estabelecimento prisional no momento em que era submetido ao scanner corporal.

Saliente-se que a majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, não deixa de incidir apenas em razão do fato de o autor do delito ser detento, pois a lei não faz distinção.

Nesse sentido:

“De igual modo, é caso de manter o aumento decorrente do fato de ter sido praticado o delito nas dependências de estabelecimento prisional, incidindo, na espécie, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Ressalte-se que referida majorante não deixa de incidir quando o agente é detento do presídio, porquanto a lei não traz qualquer particularização a respeito da característica do autor do crime. O colendo Superior Tribunal de Justiça já havia assentado entendimento de que a causa de aumento prevista no inciso IV do artigo 18 da antiga Lei n. 6.368/76 era aplicável ao presidiário que comete o crime de tráfico de entorpecentes nas dependências do estabelecimento penal: 'Para incidência da causa de aumento prevista no artigo 18, inciso IV, da Lei n.

6.368/76, in casu, delito cometido dentro do estabelecimento penal, pouco importa que o crime tenha sido praticado por agente que esteja em liberdade ou por preso. (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ)'. (REsp 662779/MG; Recurso Especial 2004/0078379-7, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma)." (em TJSP, Apelação n. 0000339-05.2010.8.26.0326, Rel. Borges Pereira, j. 04/12/2012).

Assim, deve a pena ser majorada na proporção de um sexto, resultando em sete anos, dez meses e quinze dias de reclusão, mais setecentos e oitenta e seis dias-multa. Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas.

Ante o montante da pena aplicada, os maus antecedentes e a reincidência, inclusive específica, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar o réu Marcos Vinicius de Moraes como incurso nas penas do artigo 33, caput, combinado com artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11343/2006, a cumprir sete anos, dez meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar setecentos e oitenta e seis dias-multa, calculado o valor do dia-multa no piso mínimo.

Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

P.R.I.

Bauru, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA